

1500368-36.2020.8.26.0550

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/07/2022

... não foram apreendidos outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes em poder do réu e nenhum outro elemento foi trazido aos autos de forma a indicar a efetiva prática do tráfico de drogas por ele na data dos fatos.

Além disso, o réu é primário e portador de bons antecedentes. Não foram presenciados atos de venda e não há histórico dele com o tráfico de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, Rio Claro-SP - cep 13500-380

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500368-36.2020.8.26.0550 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500368-36.2020.8.26.0550

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2309425/2020 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 15166986 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO,

7650/20/924 - DEL.SEC.RIO CLARO PLANTÃO, 2309425 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

7650/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

VICTOR GABRIEL CORREA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Vistos.

VICTOR GABRIEL CORREA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque no dia 11 de dezembro de 2020, por volta das 18h30min, no cruzamento da Avenida 62 com a Rua 11, Jardim Olinda, nesta comarca de Rio Claro, teria vendido, trazido consigo e guardado, para fins de comércio, 78 cápsulas contendo 27,1 gramas de cocaína (conforme auto de exibição e apreensão e laudo de constatação), substância que é entorpecente e que determina a dependência física e psíquica do agente, fazendo-o sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 18/20) e exame químico-toxicológico (fls. 75/77).

O réu Victor foi notificado (fls. 83), apresentou resposta escrita (fls. 97/99) e a denúncia foi recebida (fls. 107/109).

Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais na forma de memoriais, nos termos do art. 403, §3º, do Código de Processo Penal.

Em sede de memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia, concordou com a fixação da pena-base no mínimo legal, e o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como discordou da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (fls. 133/138)

A Defesa, por seu turno, preliminarmente, requereu o reconhecimento da nulidade processual ante a ausência de citação do acusado. No mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório, e subsidiariamente requereu a desclassificação para o delito previsto no art. 28, "caput", da Lei 11.343/06. Também pugnou pelo reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, bem como pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06. (fls. 145/156)

É o relatório.
FUNDAMENTO E DECIDO.

Atestado em ambos os laudos que a substância apreendida consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06.

Inicialmente, não merece prosperar a preliminar arguida pela Defesa de nulidade processual decorrente da ausência de citação do acusado.

Compulsando os autos, verifica-se que o acusado já estava plenamente ciente da existência da ação penal, da acusação imputada e da prerrogativa de apresentar defesa, uma vez que foi regularmente notificado, tendo inclusive declarado já possuir advogado constituído. No entanto, em razão do decurso do prazo sem oferecimento da resposta escrita, passou a atuar no caso a Defensoria Pública, que apresentou a medida legal cabível às fls. 97/99.

Cumprido observar ainda, conforme despacho de fls. 90, que foi determinada a intimação do réu acerca da inércia de seu advogado e de que poderia constituir outro, a qualquer tempo, tendo o acusado sido intimado às fls. 95 (no mesmo endereço em que havia sido notificado às fls. 83) de seu conteúdo, o que reforça ainda mais a tese de que detinha ciência acerca do andamento da ação penal em seu desfavor.

Na sequência, verifica-se que a tentativa de citação, após o recebimento da denúncia, foi realizada no mesmo endereço que constava dos autos e no local em que ele havia sido anteriormente notificado e intimado das decisões anteriores, conforme depreende-se das fls. 83 e 95.

Desse modo, não há que se falar em nulidade do procedimento se o réu, a quem cabe manter seu endereço atualizado durante a ação penal, não foi encontrado no endereço por ele indicado para receber intimações dos atos processuais, sendo que tal decisão está em consonância ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão

vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATO LIBIDINOSO DIVERSO DA CONJUNÇÃO CARNAL. NULIDADE PELA AUSÊNCIA DO RÉU NO INTERROGATÓRIO. INOCORRÊNCIA. NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE DO CRIME. LAUDO DE VIOLÊNCIA SEXUAL SEM LESÕES FÍSICAS OU PSICOLÓGICAS. GENITORA CONSIDERADA MERA PORTA-VOZ DO MENOR. TENRA IDADE (DOIS ANOS). FALTA DE AFERIÇÃO DA SUA CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO. 1. Como o próprio acusado deixou de cumprir espontaneamente com a obrigação de atualização do seu endereço no feito, não poderia alegar a nulidade a que ele mesmo deu causa (art. 565 - CPP). 'O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar o novo endereço ao juízo' (art. 367 -CPP). [...]6. Agravo regimental provido para conhecer e dar provimento ao recurso especial para absolver o réu por ausência de provas da materialidade do crime (art. 386, II e VII - CPP)."

(AgRg no AREsp 1961564/PR, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 02/03/2022, grifei.) g.N.

Outrossim, para que o instituto da nulidade processual seja reconhecido, faz-se necessário a ocorrência de efetivo prejuízo para a acusação ou defesa ou tenha influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, o que não restou demonstrado no presente caso.

Ademais, contrariamente ao que foi alegado pela Defesa em seu parecer, mas em consonância ao que foi mencionado pelo STJ em decisão recente: "Conforme explica Badaró, a "notificação" para o oferecimento da resposta escrita, tem natureza de citação, uma vez que dá ciência ao acusado de existe um processo penal contra ele, facultando-lhe comparecer em juízo para se defender. O legislador, partindo da premissa equivocada de que não existe processo antes do recebimento da denúncia, preferiu denominar tal ato de notificação, para somente após o recebimento da denúncia referir-se à "citação" (CPP, art. 517)". (STJ - RHC: 143956 ES 2021/0073705-4, Relator: Ministro FÉLIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 02/08/2021) g.N.

Nesse contexto, da análise dos autos, não se constata nenhum prejuízo ao acusado, pelo contrário, verifica-se que a Defesa ofereceu resposta escrita, compareceu à audiência de instrução designada, bem como apresentou suas alegações finais na forma de memoriais, de modo que não se vislumbra que a garantia ao contraditório e à ampla defesa restaram prejudicados.

No mesmo sentido tem se posicionado a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. DEFESA PRÉVIA. RÉU REVEL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE CITAÇÃO. CONHECIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA TÉCNICA AO LONGO DE TODO O PROCESSO. II - INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM INOCORRENTE. NATUREZA DA DROGA. PRIMERA FASE DA DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. RÉU DEDICADO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. MOTIVAÇÃO DIVERSA. 1. A alegação da falta de citação, por si só, não leva à nulidade do processo se está demonstrado nos autos que o réu foi notificado para apresentar a defesa prévia e foi patrocinado no transcorrer de toda causa por defensor público que realizou, com vigor, o contraditório. 2. Segundo se extrai da operação de individualização da pena, a natureza e quantidade de drogas serviu para

a fixação da pena base, enquanto que a negativa do tráfico privilegiado se baseou na comprovação de que um os réus se dedicavam à atividade criminosa, o que é matéria a ser enfrentada somente em sede de cognição plena, independentemente de a reincidência recair apenas quanto a um dos apenados. Agravo desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 418977 SP 2017/0255423-0, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 19/06/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2018) g.N.

Assim, afasto a preliminar de nulidade processual decorrente da ausência de citação do acusado, eis que não reúne condições para prosperar, nos termos acima delineados.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 16), laudo de constatação (fls. 18/20) e exame químico-toxicológico (fls. 75/77).

A autoria foi demonstrada a contento.

Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que possui 18 anos e, na data dos fatos, foi cortar o cabelo. Tinha consigo R\$ 70,00, que recebeu trabalhando em uma pizzaria. Pagou R\$ 20,00 pelo corte e, em seguida, usou os R\$ 50,00 para comprar 7 eppendorfs amarelos para si. Assim que os adquiriu, os policiais chegaram de motocicleta. Encontraram consigo os sete eppendorfs. Nenhum dinheiro foi encontrado. Comprou as drogas de um rapaz que estava na "biqueira", o qual não sabe informar os dados. Disse que o rapaz que lhe vendeu a droga não foi abordado pelos policiais. Não conhece o indivíduo que foi abordado consigo, mas os policiais nada encontraram em posse dele. É usuário de cocaína e maconha (fls. 09).

Em juízo, foi decretada sua revelia ante a sua não localização.

A testemunha comum, Lucas Henrique Ferreira dos Santos, policial militar, declarou que estava em patrulhamento pelo bairro Jardim Olinda juntamente com seu parceiro, quando ao acessar o cruzamento da Avenida 62 com a Rua 11, foram avistados dois indivíduos próximos um ao outro, os quais, ao notarem a equipe policial, demonstraram nervosismo, motivando a abordagem. Em revista pessoal, foram localizados 7 eppendorfs de cocaína na posse de Victor. Ainda, no bolso da bermuda de Alisson, foram localizados 2 eppendorfs e a quantia de R\$ 10,00. Após a revista pessoal, realizaram a varredura nas proximidades do local da abordagem e foram localizados mais 69 eppendorfs de cocaína no interior de uma sacola plástica. Indagados a respeito, Victor confessou que estava realizando a venda dos entorpecentes, enquanto Alisson disse que estava adquirindo as drogas. Já os havia abordado anteriormente. Teve conhecimento que Victor ainda traficava após essa ocorrência, mas não o abordou novamente. A distância do local em que eles estavam para o local onde foi localizada a sacola era entre 5 e 10 metros. (SAJ)

De rigor a desclassificação do delito previsto no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06 para o previsto no art. 28, "caput", da mesma Lei, pois as provas amealhadas nos autos são frágeis para expedir um decreto condenatório imputando ao réu a destinação mercantil dos entorpecentes localizados sob sua posse, bem como a propriedade dos demais entorpecentes localizados, senão vejamos.

Quando ouvido na fase inquisitiva, o réu negou fatos. Disse que é usuário de drogas. Afirmou que detinha consigo a quantia de R\$70,00. Utilizou R\$20,00 para cortar o cabelo. Posteriormente, deslocou-se até a biqueira e adquiriu 7 eppendorfs amarelos com os R\$50,00 que havia sobrado. Os policiais o abordaram quando havia

acabado de adquirir os entorpecentes. O rapaz que lhe vendeu as drogas não foi abordado pelos policiais. Desconhece o rapaz que foi abordado juntamente com ele, sendo que sob a posse dele nada foi localizado.

De outro lado, o policial militar que efetuou a abordagem do réu, quando ouvido em Juízo, declarou que realizava patrulhamento pelo bairro Jardim Olinda quando avistaram dois indivíduos próximos um ao outro que ao notarem a equipe policial demonstraram nervosismo. Efetuaram a abordagem e sob a posse de Victor localizaram 07 eppendorfs. No bolso da bermuda de Alisson encontraram 02 eppendorfs e a quantia de R\$10,00. Realizaram uma varredura nas proximidades e há cerca de 05 a 10 metros de distancia do local localizaram 69 eppendorfs de cocaína no interior de uma sacola plástica. Disse que ele confessou informalmente a pratica do delito.

Nessa toada, verifica-se que a prova colhida deixa sérias dúvidas acerca da destinação da droga apreendida na ocasião dos fatos.

É certo que os relatos prestados pelos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão dos réus gozam de presunção de legitimidade, pois decorrentes de atividade funcional de agentes públicos, o que implica na verossimilhança das alegações.

Outrossim, não se desconhece que para a configuração do delito de tráfico não é indispensável que o agente seja preso no ato da mercancia ou após vender a droga. Entretanto, é necessário que a destinação mercantil da droga apreendida seja devidamente comprovada, o que não ocorre nos presentes autos.

Compulsando os autos, não se vislumbra provas robustas para comprovar seguramente o vínculo do réu com as demais substâncias entorpecentes apreendidas pelos policiais militares nas proximidades do local em que foi efetuada a abordagem, não bastando, para tanto, somente a presença de indícios isolados ou eventual certeza moral da ocorrência do delito.

Como se vê, não foram apreendidos outros materiais relacionados ao tráfico de entorpecentes em poder do réu e nenhum outro elemento foi trazido aos autos de forma a indicar a efetiva prática do tráfico de drogas por ele na data dos fatos.

Além disso, o réu é primário e portador de bons antecedentes. Não foram presenciados atos de venda e não há histórico dele com o tráfico de drogas.

Como se não bastasse, quanto aos entorpecentes localizados em poder do réu, cumpre salientar que a quantidade de drogas apreendidas (07 eppendorfs de contendo cocaína - conforme declarações do próprio réu e do policial militar quando ouvidos em Juízo), apesar de não ser ínfima, não está a descaracterizar a destinação de uso.

Por esses motivos, impossível a condenação no tráfico de drogas, diante da ausência de comprovação do destino mercantil das drogas apreendidas, sendo de rigor a desclassificação do crime para o de porte de entorpecentes.

Conforme preceituado no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

Assim, da análise de todas as determinantes legais, concluo que o réu portava a droga localizada em seu poder para consumo próprio.

Não há que se falar em inconstitucionalidade do delito imputado ao réu, tendo em vista que a disposição contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06 se trata de norma

penal válida e eficaz, emanada do poder competente, que atende à política criminal adotada.

O fato de o referido dispositivo não prever pena privativa de liberdade, mas somente outras medidas, que visam a conscientização e recuperação do usuário de drogas, não retira o caráter criminal da conduta.

A condenação, com todos os seus gravames e consequências, só pode apoiar-se em prova cabal e estreme de dúvidas. Presunções e indícios não ostentam aquela qualidade de certeza, pelo que não servem para fundamentar um decreto condenatório. Só a certeza probatória pode alicerçar uma condenação.

Destarte, conforme tenha sido apreendida substância entorpecente em poder do acusado, e o mesmo tenha confessado ser usuário, impõe-se a desclassificação do delito de tráfico para o de uso.

Operada a necessária desclassificação, passo a analisar a pena.

Diante da ausência de antecedentes pelo réu, reputo a pena de advertência suficiente.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra VICTOR GABRIEL CORREA para CONDENÁ-LO à uma pena de advertência, como incurso no artigo 28, "caput", da Lei 11.343/06.

Determino a destruição das drogas, caso ainda não tenha sido feita.

Custas "ex lege".

Publique-se. Intimem-se.

Rio Claro, 14 de julho de 2022.

CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA